

1500150-94.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Gustavo de Oliveira se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

O réu Jhonatan Gustavo de Oliveira, aliás, confessou em juízo a prática delitiva.

Disse que estava no local traficando drogas, e o outro acusado era apenas usuário e não tinha qualquer relação com o tráfico.

Por outro lado, não há elementos probatórios que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500150-94.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500150-94.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018499/2022 - DEL.POL.ITAPEVI, 22559219 - DEL.POL.ITAPEVI, 193/22/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2018499 - DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AUGUSTO PEREIRA SOARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

JHONATAN GUSTAVO DE OLIVEIRA e MARCOS AUGUSTO PEREIRA SOARES, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 10h45min, na Rua Maria Nazaré dos Reis, altura do n.º 10, Jardim Portela, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (f. 91 e 95) e apresentaram defesa prévia (f. 101-104).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 20 de junho de 2022 (f. 105-106).

Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 149). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 144-145).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 12-13, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como a quantia de R\$ 61,00.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 73-75), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Por outro lado, restou comprovada apenas a autoria de Jhonatan Gustavo de Oliveira. Observe-se.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram os réus num escadão. Fizeram um cerco, e o réu Marcos Augusto Pereira Soares correu quando avistou a viatura, tropeçou no escadão e caiu; o acusado Jhonatan Gustavo de Oliveira ficou parado no local e, em sua posse, havia uma sacola com drogas e uma quantia em dinheiro, tendo ele confessado que estava vendendo os entorpecentes. Em poder do denunciado Marcos Augusto Pereira Soares nada foi encontrado; porém, ele já foi visto naquele lugar algumas vezes, sempre na ponta do escadão, figurando como olheiro para avisar quando chega a polícia; no momento da prisão em flagrante, ele disse que estava lá apenas para comprar drogas.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais militares, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado Jhonatan Gustavo de Oliveira se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

O réu Jhonatan Gustavo de Oliveira, aliás, confessou em juízo a prática delitiva. Disse que estava no local traficando drogas, e o outro acusado era apenas usuário e não tinha qualquer relação com o tráfico.

Por outro lado, não há elementos probatórios que amparem a condenação do acusado Marcos Augusto Pereira Soares.

O réu, em solo policial, negou a prática delitiva e afirmou ser usuário de drogas. Disse que estava no local para comprar maconha quando houve a abordagem (f. 08). Em juízo, manteve a coerência e apresentou a mesma versão dos fatos, alegando ser apenas usuário.

O réu Jhonatan Gustavo de Oliveira corroborou as suas alegações. Em seu interrogatório, afirmou que era o único que estava vendendo drogas no local, e que o corréu estava lá apenas para adquirir os entorpecentes.

Outrossim, os policiais militares, em juízo, asseveraram que nada encontraram em posse de Marcos Augusto Pereira Soares, nem dinheiro, tampouco substâncias ilícitas. E apenas uma das testemunhas afirmou que ouviu o réu avisando que os policiais haviam chegado; a outra, nada presenciou nesse sentido.

No ponto, ainda que o réu tenha, de fato, avisado o corréu ao avistar a viatura, isso não é suficiente para configurar sua autoria no delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Como é notório, usuários de drogas também se assustam com a presença da polícia, sendo verossímil a hipótese de o acusado ter gritado e empreendido fuga na mera condição de usuário - e não traficante.

Nesses termos, impõe-se a absolvição do réu Marcos Augusto Pereira Soares, nos termos do art. 386, V, do CPP, já que ausentes provas inequívocas de seu envolvimento no delito.

As provas, portanto, são bastantes apenas para a condenação do réu Jhonatan Gustavo de Oliveira.

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu não preenche o primeiro requisito, pois é reincidente específico no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme certidão de f. 138.

Não faz jus, portanto, à incidência da circunstância privilegiadora.

Há, pois, subsunção da conduta do acusado Jhonatan Gustavo de Oliveira ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, trazia consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para: (a) absolver o réu MARCOS AUGUSTO PEREIRA SOARES, na forma do art. 386, V, do CPP; e (b) condenar o réu JHONATAN GUSTAVO DE OLIVEIRA, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valorização de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da

pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado ostenta uma condenação criminal já transitada em julgado, a qual será valorada, contudo, na segunda fase da dosimetria, como reincidência (f. 138-140).

Todavia, verifica-se que essa condenação anterior foi também por tráfico de drogas, circunstância que demonstra a personalidade dissonante do denunciado, que é voltada à prática desse delito, equiparado a hediondo.

Outrossim, importante ressaltar que as circunstâncias do crime também são desfavoráveis. Com efeito, o denunciado estava na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais negativas preponderantes, fixo a pena base em 08 anos de reclusão – e 800 dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa para ser considerada, nos termos do art. 65, I, do CP, tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (f. 16).

Há, outrossim, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática do delito.

Reconheço, também, a agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme certidão de f. 138-140, o acusado cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Assim, em consonância com o C. Superior Tribunal de Justiça, que pacificou, no julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP, deixo de exasperar ou diminuir a reprimenda em relação a essas duas circunstâncias, considerando-as compensadas entre si.

Assim, deve a pena ser reduzida em 1/6, apenas em relação à atenuante da menoridade. Por isso, reduzo a reprimenda e fixo-a em 06 anos e 08 meses de reclusão – e 666 dias-multa, provisoriamente.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, fixo a pena, agora definitivamente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais.

Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o

preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado Jhonatan Gustavo de Oliveira, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Tendo em vista o deslinde do feito em relação ao réu Marcos Augusto Pereira Soares, expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelo réu condenado (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA